

1500780-80.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500780-80.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE JESUS SENA

Data da Audiência:

01/09/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 01 de setembro de 2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Pavia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu Defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença da DD. Representante do Ministério Público a DRA. MARÍLIA BONONI FRANCISCO. Presente o réu LEANDRO DE JESUS SENA e seu Defensor o Dr. RODRIGO GARCIA DA SILVA -OAB 357447/SP. Presentes as testemunhas RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, GABRIEL EDUARDO MOTTA DE LIMA e GILSON LUIS VILELA. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas

RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, GABRIEL EDUARDO MOTTA DE LIMA e GILSON LUIS VILELA e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra a DD. Promotora de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

LEANDRO DE JESUS SENA, qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de junho de 2022, por volta das 23:15 horas, na Rua Pedro Merluzzi, n.405, Jardim Luchetti, na cidade de Fernando Prestes e Comarca de Taquaritinga, trazia consigo 19 (dezenove) papelotes de "cocaína", pesando 15,3 gramas e 06 (seis) eppendorfs contendo "crack", pesando 3,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 37/38), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.43) e laudos periciais (fls.103/105 e 106/108), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 167) e apresentou defesa prévia (fls. 157/163).

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 186/191) e, designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, de forma híbrida, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para os delitos previsto nos artigos 28 e 33, § 3º, da Lei de Drogas. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, deve ser rejeitado o pedido formulado pela defesa para a instauração de incidente de dependência toxicológica em relação ao acusado, pois não há prova documental que indique a dependência alegada, sendo certo que meras afirmações não bastam para a instauração do incidente. A esse respeito, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DO PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO DOWRIT QUANTO A ESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE SEMIIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. 1. Correto o acórdão ora impugnado quanto ao fundamento de que não seria possível aferir, na espécie, a semiimputabilidade do Paciente, pois nem sequer foi instaurado, em qualquer fase do processo, o incidente de insanidade mental - única forma possível de se aferir o estado mental do Acusado. Além disso, não consta nos autos qualquer insurgência quanto à ausência de instauração do referido incidente. 2. Observa-se, da análise dos documentos colacionados aos autos, que não houve, durante a instrução criminal, e tampouco restou demonstrado neste mandamus, dúvida relevante acerca da saúde mental do ora Paciente capaz de justificar a instauração do incidente de ofício pelo Magistrado de primeira instância. 3. A dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado enseja a instauração do incidente de insanidade mental, sendo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o

Juiz a determinar a sua realização, nem tampouco a instauração do procedimento de ofício. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 142.344/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, DJ de 8/9/2011, 5ª Turma).

Nesse caso, inexistindo prova segura da alegada dependência química, o pedido deve ser rejeitado.

No mérito, o pedido na ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 34/36 e 86/92), auto de exibição e apreensão (fls. 37/38), fotografias (fls. 39/41), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 43), laudos periciais (fls. 103/105, 106/108, 221/224), mídia (fls. 215), auto de materialização de evidência eletrônica (fls. 227/250) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Na fase policial, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu alegou que tem 31 anos de idade e trabalha na roça. Alegou que estava na casa da namorada e disse a ela que iria embora, porém, acabou passando pelo local para comprar drogas. Afirmou que usou o dinheiro do pagamento para comprar drogas, pela quantia de R\$ 300,00. Alegou que não estava na posse de nenhum aparelho celular. Alegou que não tem apelido. Disse que ganhava R\$ 80,00 por dia de trabalho e não R\$ 60,00, como constou no inquérito policial. Afirmou que não conhece "Melaine", eis que sua namorada se chama "Érica". Não se lembra do número do seu celular. Alegou que a sua namorada mora na quarta casa da rua, perto da "pracinha". Alegou que comprou as drogas para uso próprio. Alegou que continua namorando, mas ela se comunica por carta. Alegou que sua bolsa com roupas está no CDP de Taiuva.

Todavia, a versão dada pelo réu se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A testemunha de acusação Rafael Fernandes de Alencar, policial militar, declarou que durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Santo Antônio, um transeunte que não se identificou, informou que no Jardim Lucheti, uma pessoa estaria promovendo o tráfico de drogas. Disse que, de acordo com tal transeunte, tratava-se de pessoa do sexo masculino, vestindo blusa cinza, com detalhe branco e vermelho. Diante da informação, dirigiram-se para o local. Quando estavam na Rua Pedro Merluzzi, avistaram o acusado, cujas características coincidiam com o que foi relatado pelo denunciante. Contou que assim que o acusado percebeu a presença da viatura policial, ele segurou a bolsa que carregava e tentou arremessá-la dentro de um dos imóveis existentes na rua, vindo a ser impedido diante da abordagem. Efetuada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado junto ao réu. Efetuada vistoria na bolsa, encontraram 19 papелotes com "cocaína" e 06 eppendorfs contendo pedras de "crack". Relatou que com o agente também havia um aparelho celular, que foi apreendido. Ao ser indagado sobre as drogas, o acusado se declarou usuário e afirmou tê-las adquirido pelo valor de R\$ 300,00, dizendo que iria fazer uso delas. Contou que ao avistar o réu, ele estava sentado no local da abordagem. Alegou que o réu mora em Santa Adélia. Esclareceu que os usuários não permanecem no local. Disse que não havia mais ninguém no local. Aduziu que foi ele que vasculhou a mochila. Afirmou que dentro da mochila também havia roupa. Não se recorda onde estava o celular. Alegou que o réu é bem conhecido dos meios policiais e já foi abordado por ele outras vezes.

A testemunha de acusação Gabriel Eduardo Motta de Lima, policial militar, declarou que na data dos fatos, durante patrulhamento pelo Bairro Santo Antônio, uma pessoa, que não quis se identificar, relatou que pelo bairro Jardim Lucheti, havia um homem moreno, de blusa cinza, com detalhe branco e vermelho, provendo o tráfico de drogas. Diante da informação se dirigiram para o local, com o fim de verificarem a denúncia. Quando estavam no indigitado bairro, pela Rua Pedro Merluzzi, avistaram o agente, cujas características coincidiam com o que foi relatado pelo denunciante. Quando o acusado percebeu a presença da viatura policial ele tentou arremessar a mochila que portava em um dos imóveis, mas devido a abordagem, não conseguiu. Efetuada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado junto ao corpo do acusado. Realizada vistoria na bolsa, foram localizados 19 papелotes contendo "cocaína" e 06

eppendorfs com pedras de "crack" em seu interior. Com o acusado também havia um aparelho celular. Ao ser indagado sobre as drogas, o réu disse que as adquiriu por R\$ 300,00 e que iria consumi-las. Afirmou que o réu é conhecido de outras abordagens. Afirmou que tinham informações de que o réu estava praticando a venda de drogas. Afirmou que não se recorda quem fez a busca na mochila. Esclareceu que havia roupas na mochila, sendo que o réu pediu para deixar para populares. Anotou que o réu não é de Fernando Prestes mas sempre é visto na cidade.

A testemunha de defesa Gilson Luis Villela declarou que é conhecido do acusado.

Afirmou que conhece Leandro há 03 ou 04 anos. Anotou que sabia que o réu teve passagem pela polícia. Afirmou que o réu mora em um imóvel dentro da sua propriedade. Afirmou que de vez em quando o réu lhe prestava serviço de diarista, sendo o serviço braçal. Afirmou que percebeu que o réu era usuário de drogas. Nunca viu o réu usando entorpecente. Contou que o comportamento do réu é "normal". Alegou que nunca suspeitou que o réu estivesse comercializando drogas, tendo ficado surpreso. Não soube dizer se o réu tem algum relacionamento amoroso.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao imputar ao réu a posse de 19 papetes com "cocaína", além de 06 eppendorfs contendo "crack", acondicionados em uma mochila que ele carregava.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PROVIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que

qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei.

Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Note-se que, durante a abordagem, o acusado tentou se desfazer da mochila em que carregava as drogas e o aparelho celular.

Ademais, não prospera a alegação de que as drogas encontradas com o acusado seriam para seu próprio uso. Veja-se que ele afirmou ter adquirido os entorpecentes pela quantia de R\$ 300,00, valor elevado, considerado os rendimentos informados a fls. 27 dos autos, de R\$ 80,00 por dia de trabalho.

No mais, durante a abordagem, na posse do réu, foi apreendido um aparelho celular e, realizada perícia, foi elaborado o laudo de materialização de evidência eletrônica (fls. 227/250), cujo conteúdo das conversas extraídas confirmam o amplo envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Às fls. 245 e seguintes fica evidente que a pessoa identificada como "Milaine da Silva Soares", que supostamente, exerce posição de liderança na prática do tráfico, a qual, inclusive, identificou-se como "gerente" da biqueira, também utilizava o celular apreendido na posse do réu (fls. 229). O diálogo de fls. 231 evidenciou que Leandro auxiliava "Milaine" na biqueira.

Corroborando com tal informação, extrai-se excerto do diálogo entre os usuários identificados por "Lele" e "Negao", em que este solicita drogas a Leandro.

"Negao: O Marcão falou se vc se vc pode pode solta uma pra ele.

Lele: Oi o lelei não tá aqui ele deixou commigo o celular dele.

Negao: Quem e

Lele: E a milaine. Pq" (sic - fls. 246).

Assim, as conversas denotam que o celular apreendido com o acusado também era utilizado por "Milaine", que é a "gerente" da biqueira.

O laudo em destaque também indicou diálogo por áudio entre um interlocutor identificado com número "16993408048", o qual questiona Leandro se teria "algo" naquela semana, referindo-se à certa quantia de drogas, tendo o acusado respondido que estava "a procura de um 'chão' para guardar as caminhadas" (fls. 247).

Ademais, o mesmo interlocutor diz ao acusado que está sem drogas e que quando chegar, é para avisá-lo (fls. 248). Ainda, ao ser questionado se "a lojinha já estava funcionando", o réu responde que a biqueira estava funcionando desde as 06h (fls. 248).

Assim, diante do teor dos diálogos em destaque, não há dúvidas do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, especialmente porque não soube explicar a origem do celular localizado no interior de sua mochila.

Nesse contexto, as circunstâncias, a quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam embaladas autoriza a considerar que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Cumprе anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário, para a sua caracterização, o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do

dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelos dois policiais militares e a prova pericial coligida, constituem provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que o réu realmente trazia consigo drogas, no local em que foi detido em flagrante, na ocasião. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuía não eram destinadas ao uso. Neste sentido: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

No mais, inexistente prova nos autos de que a droga se destinava ou uso compartilhado. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Nesta senda, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, já que a "cocaína" possui efeitos devastadores.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica "cocaína" deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil demonstrado - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal - Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento - Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência - Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal - Inaplicabilidade - Requisitos legais não

preenchidos - Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada - Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agrado regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Ainda, o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes de fls. 263/265 (Proc. 0055956-97.2012.8.26.0222 - extinta pelo cumprimento em 29.04.2019 - fl. 64).

Importa consignar que, conforme Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a valoração de condenações anteriores na primeira e na segunda etapa da dosimetria da pena, quando se tratam de condenações distintas.

À propósito:

DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATAM DE PROCESSOS DISTINTOS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, ou mesmo de ofensa ao enunciado sumular 241 deste Sodalício, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. (...) 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para reduzir a pena-base do paciente para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. (HC 334.643/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) - grifei.

Pena base, portanto, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a computar. Incide a agravante da reincidência, conforme se verifica da certidão acostada às fls. 54/65 dos autos (Proc. nº 0051829-19.2012.8.26.0222 e 0204034-38.2009.826.0222 - fim da execução em 29.04.2019 - fl. 62/64), majorando a pena em 1/6. Pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizado o mesmo critério das privativas de liberdade, é fixada em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para o réu, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o fechado, ante a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda combate diuturno das autoridades policiais, judiciárias e do Ministério Público.

Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra LEANDRO DE JESUS SENA, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Pelas circunstâncias do caso concreto e considerando-se que o réu se encontra preso desde o flagrante, além de ser reincidente específico, não se justificaria a soltura após a condenação. Nego-lhe, portanto, o apelo em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Diante da pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade que ora defiro.

P.I.C."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto o Defensor quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. Servirá o presente termo, por cópia digitada e acompanhado da sentença, devidamente assinados como ofício de recomendação do réu à prisão em que se encontra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA